

1501112-02.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2140324/2022 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hernanis de Sousa Cruz

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

HERNANIS DE SOUZA CRUZ, qualificado as fls. 04/06, está sendo processado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501112-02.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501112-02.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2140324/2022 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hernanis de Sousa Cruz

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

HERNANIS DE SOUZA CRUZ, qualificado as fls. 04/06, está sendo processado como

incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de maio de 2022, por volta das 14h00, na Avenida das Nações, altura do n.º 280, bairro Taboão, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 10,94 gramas, 30 (trinta) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 3,66 gramas e 58 (cinquenta e oito) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 39,35 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudos de constatação provisória de fls. 19/21 e de exame químico toxicológico de fls. 61/62.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 33/36). Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 30/08/2022 (fl. 95) e certificada a notificação e a citação positiva do Réu, sendo nomeado Defensor Público com apresentação de defesa preliminar às fls. 91/92.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, com considerações acerca da pena e regime de resgate.

Já o d. Defensor reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal dada à primariedade do acusado, com a redução pela atenuante da confissão, e o redutor máximo da pena ainda por ser tráfico privilegiado, além da substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade ante a detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Ausentes questões preliminares, passo ao mérito da ação, que procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.16/17, nos autos de constatação e no definitivo (fls. 19/21 e 60/62), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.02/03), durante patrulhamento pela Avenida das Nações, em local conhecido como ponto de venda de drogas, deparou com um indivíduo que ao perceber a aproximação da viatura policial passou a caminhar a passos rápidos no sentido contrário, motivo pelo qual decidiram abordar o suspeito para averiguação. O indivíduo identificou-se como HERNANIS DE SOUZA CRUZ. Na busca pessoal realizada logrou êxito em localizar em poder do suspeito, no interior de uma bolsa tiracolo, 30 pedras de substância semelhante ao "crack", 58 porções de erva semelhante à maconha e 14 papелotes de pó branco semelhante a cocaína, além da importância de R\$ 82,00. Durante a entrevista, o suspeito confirmou que estava vendendo os entorpecentes.

Em juízo, a testemunha Gustavo Tadeu Teixeira asseverou estavam em patrulhamento, quando acessaram o local por meio de uma viela (o local é ponto de venda de drogas), ao que seu parceiro adentrou por outro acesso. O réu ao avistar a guarnição deu fuga, sentido Avenida das Nações, ao que acessou um comércio e pegou uma lata de cerveja. Abordou o réu, e localizou com ele uma bolsa, com drogas, admitindo o réu a traficância. Havia também dinheiro.

Perante ao Juiz Imparcial, a testemunha Thiago da Silva Ré prestou depoimento em sentido similar.
O indiciado, extrajudicialmente (fl. 06), ficou-se silencioso.

Sob o crivo do contraditório, o réu confessou os fatos em que fundada a pretensão punitiva.

Não bastasse isso, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Isso porque: o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age falciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares ter em depósito e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade das drogas (maconha e cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (R\$ 34,00), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, pelo que mantenho a pena base em valores mínimos.

Em segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena intermediária em valores mínimos.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu não faz jus ao beneplácito legal, dada a reincidência que traz em seus antecedentes..

Atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a quantidade da pena de um lado e de outro, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência específica, fixo o regime prisional fechado. Neste sentido inclusive: "(...) Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo ilegalidade a ser sanada. Precedentes." (STJ, HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18/10/2016).

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo

constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 10, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-los inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: "(...)Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...)” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do réu mediante desde a data dos fatos, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: “A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração .Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena ”(STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir

uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra HERNANIS DE SOUZA CRUZ, qualificado as fls. 04/06, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-los à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos dias) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos. O réu não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere compatível como regime ora fixado.

Sendo ele beneficiário de acesso gratuito à Justiça, reconheço suspensão a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fls. 56/57), com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA